

1013630-82.2021.8.26.0451

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... estável, para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Restou certa apenas a associação entre FELIPE E CARLOS ALBERTO (o interrogatório de FELIPE nos autos 1500009-02.2021.8.26.0599 deixa certo que ele e CARLOS ALBERTO estavam associados para a venda de drogas: "Pegava a droga no local. Já havia pego a droga três vezes na casa. Pegava droga com uma quarta pessoa que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1013630-82.2021.8.26.0451

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Manesco e outros

Artigo da Denúncia:

*

Tramitação prioritária

Aos 09 dias do mês de novembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se (o)a Exmo(a). Sr(a). Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel (def.Luiz Gustavo e Carlos) e dr. Lusival Santos Gaspar Dutra Júnior (def.Felipe). Apresentados os acusados FELIPE MANESCO, LUIZ GUSTAVO DINIZ ESPANA E CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO, e as testemunhas Juliane Helena Oliveira Gouveia e Eva Leme da Silva Oliveira. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pelo(a) MM. Juíz(a) foi(ram)

colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Juliane e Eva), pelo sistema virtual e, em seguida, interrogados os réus (Felipe, Luiz Gustavo e Carlos).

Em seguida, pelo(a) MM Juiz(a) foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiz(a), FELIPE MANESCO e LUIZ GUSTAVO DINIZ ESPANA estão sendo processados como incurso no artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06 e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO como incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06 combinado com o artigo 29, do Código Penal.

Procede parcialmente a ação penal.

A bem da verdade, embora agindo em conjunto na data dos fatos, não é possível dizer que os três estavam associados, de forma estável, para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Restou certa apenas a associação entre FELIPE E CARLOS ALBERTO (o interrogatório de FELIPE nos autos 1500009-02.2021.8.26.0599 deixa certo que ele e CARLOS ALBERTO estavam associados para a venda de drogas:

“Pegava a droga no local. Já havia pego a droga três vezes na casa. Pegava droga com uma quarta pessoa que não sabe o nome. No dia dos fatos havia acabado de pegar a droga. CARLOS iria fechar o portão. Quando viu a viatura ele saiu correndo. Conhece o LUIZ GUSTAVO e ele estava fumando maconha com CARLOS. No dia em que foi preso pegou a droga com CARLOS para vender. Tinha vez que era rápido e voltava para pegar mais e pagava o CARLOS. Não existia a quarta pessoa. Não sabe dizer se LUIZ GUSTAVO ficava embalando droga no local. Pegava a droga no local e ia vender na esquina de baixo”).

Por isso, certas a responsabilidade de CARLOS ALBERTO pelas drogas que estavam sob seu poder quando da operação policial e sua associação com FELIPE.

Mas não se pode dizer a mesma coisa quanto à associação de LUIZ GUSTAVO com CARLOS ALBERTO e FELIPE. Sim, embalavam drogas naquela ocasião. Mas, com relação à participação de LUIZ GUSTAVO, seria isso um ato isolado, daquele dia, ou uma associação estável, com divisão de funções e tarefas? Os elementos de prova reunidos não esclarecem essa dúvida. E a responsabilidade de LUIZ GUSTAVO sobre as drogas já foi apurada nos autos 1500009-02.2021.8.26.0599 (condenação sendo revista em grau de recurso), situação idêntica, quanto àquelas drogas encontra-se FELIPE (também condenado naqueles autos).

Vejamos as provas.

Feito regularmente processado.

DOS FATOS

Consta que, em data não apurada do mês de dezembro de 2020, ao que consta duas semanas antes do dia 03 de janeiro de 2021, na rua Professor Mariano da Costa, nº 68, bairro Jaraguá, nesta cidade e comarca, FELIPE MANESCO, LUIZ GUSTAVO DINIZ ESPANA e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO, qualificados nos autos, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta, outrossim, que, no dia 03 de janeiro de 2021, por volta de 18h37m, na rua Professor Mariano da Costa, nº 68, bairro Jaraguá, nesta cidade e comarca, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO, qualificado a fls. 10, agindo em concurso, unidade de desígnios e previamente conluiado com FELIPE e LUIZ GUSTAVO, mantinha em depósito, guardava e preparava 186 porções de maconha, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, os denunciados estavam associados há aproximadamente duas semanas para a prática de tráfico ilícito de drogas. Para tanto, eles dividiram as tarefas e organizaram-se. O denunciado CARLOS era o responsável pela aquisição do entorpecente e ceder o imóvel, onde os denunciados reuniam-se para preparação e embalo do entorpecente. Após a preparação da droga, o denunciado CARLOS entregava parte da droga ao denunciado FELIPE, que era o responsável por vendê-lo. Contudo, na sobredita data, policiais militares patrulhavam pelo referido local, quando

avistaram e suspeitaram de dois indivíduos que saíam da residência localizada no endereço mencionado, os quais, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga. Os indivíduos foram identificados como CARLOS e FELIPE.

No local, FELIPE foi abordado, enquanto o denunciado CARLOS logrou evasão. Em poder de FELIPE, no interior de uma mochila que trazia consigo, foram apreendidas 110 porções de maconha e 65 porções de cocaína.

Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram à residência de onde eles (CARLOS e FELIPE) haviam saído e encontraram o denunciado LUIZ GUSTAVO, momento em que preparava e embalava entorpecentes. No local, foram apreendidas 186 porções de maconha, além de petrechos usados na embalagem de drogas, como rolos de filme plástico, saquinhos plásticos, duas facas, e uma balança de precisão.

Diante das circunstâncias apuradas, significativa quantidade de entorpecentes em porções individualizadas e modus operandi, apreensão de material de embalagem, inclusive balança de precisão, apurou-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas. Após, apurou-se que o denunciado CARLOS conluiou-se com os comparsas e codenunciados para a prática delitiva e mantinha e /ou guardava, e preparava o entorpecente, tendo em vista que foi flagrado deixando o local na companhia de FELIPE, oportunidade em que logrou evasão, mas veio a ser identificado a posteriori.

Outrossim, o modus operandi, significativa quantidade de entorpecente apreendida, material para preparação e embalo e interrogatório do denunciado FELIPE em juízo demonstraram que, em data não apurada, aproximadamente duas semanas antes da prisão em flagrante de FELIPE e LUIZ, eles associaram-se de forma estável e com divisão de tarefas para a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive já haviam preparado e distribuído vários “kits de droga” no local.

DA PROVA DOS AUTOS 1500009-02.2021.8.26.0599, NO QUAL SE APUROU O CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343, DE 2006, PRATICADO POR FELIPE MANESCO e LUIZ GUSTAVO DINIZ ESPANA. Da prova produzida naqueles autos, originou-se a presente ação penal: Com efeito, a testemunha Carlos Alberto Morasco, policial militar, narrou “Estava em patrulhamento ostensivo de rotina pela Rua Professor Mariano da Costa quando, na altura do número 68, visualizou dois indivíduos saindo de uma residência. Ao avistar a aproximação dos militares, um dos indivíduos, identificado como o indiciado FELIPE, parou repentinamente enquanto o outro, identificado como CARLOS, correu para o interior da casa e pulou nos telhados das residências vizinhas e conseguiu evadir-se do local. Na posse de FELIPE havia uma bolsa, dentro da qual foram localizadas cento e dez porções de substância aparentando ser maconha e sessenta e cinco porções de substância aparentando ser cocaína. No interior da residência em tela foi localizado um outro indivíduo, identificado como LUIZ, sendo que estava embalando drogas. No quarto em que estava foram localizadas cento e oitenta e seis porções de substância aparentando ser maconha e diversos objetos utilizados para preparação de drogas. Ambos confessaram que estavam no local preparando e embalando drogas para venda” (fls.02). Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial e disse que o terceiro agente seria um tal de Carlos Alberto.

No mesmo sentido o policial militar Graziano Ciola Dias que asseverou “Estava em patrulhamento ostensivo de rotina pela Rua Professor Mariano da Costa quando, na altura do número 68, visualizou dois indivíduos saindo de uma residência. Ao avistar a aproximação dos militares, um dos indivíduos, identificado como o indiciado FELIPE, parou repentinamente enquanto o outro, identificado como CARLOS, correu para o interior da casa. Seguiu tal indivíduo, mas ele conseguiu fugir pulando os telhados das residências vizinhas. Na posse de FELIPE havia uma bolsa, dentro da qual foram localizadas cento e dez porções de substância aparentando ser maconha e sessenta e cinco porções de substância aparentando ser cocaína.

No interior da residência em tela foi localizado outro indivíduo identificado como LUIZ, sendo que estava embalando drogas. No quarto em que estava foram localizadas cento e oitenta e seis porções de substância aparentando ser maconha e diversos objetos utilizados para preparação de drogas. Ambos confessaram que estavam no local preparando e embalando drogas para venda” (fls. 03).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Em nenhum momento os réus alegaram ser usuários. Lembra-se que eles alegaram que estavam no local fracionando a droga. Pela sua experiência, “no local em que é fracionada a droga não é vendida, pois chama a polícia”. O ponto de venda fica a alguns metros da residência.

Em juízo, o réu FELIPE alegou que estava sem serviço e tem duas filhas pequenas. Fazia duas semanas que estava “vendendo”. Confessou que “estava vendendo droga aos policiais porque estava necessitado em razão da pandemia. Está arrependido. Estava na rua quando foi visto pelos policiais. Não estava com Carlos e não o conhece. Conhece de vista o corréu. A bolsa estava consigo. Pegava a droga no “Vitória”, perto do campinho. Nega que estivesse com CARLOS e não saiu da casa. Não conhecia os policiais e pode ter sido confundido com alguém. Pegava a droga no Vitória. Pagou pela cocaína 400,00 e 300,00 pela maconha. Não pagava à vista. Na outra semana havia pego a mesma quantidade. Vendia a porção de maconha a 5,00 e a 10,00 a porção de cocaína. Ganhava 250,00 na maconha e 200,00 no pó”. Depois de advertido, retratou-se e confessou que “saiu da casa indicada na denúncia. Pegava a droga no local. Já havia pego a droga três vezes na casa. Pegava droga com uma quarta pessoa que não sabe o nome. No dia dos fatos havia acabado de pegar a droga. CARLOS iria fechar o portão. Quando viu a viatura ele saiu correndo. Conhece o LUIZ GUSTAVO e ele estava fumando maconha com CARLOS. No dia em que foi preso pegou a droga com CARLOS para vender. Tinha vez que era rápido e voltava para pegar mais e pagava o CARLOS. Não existia a quarta pessoa. Não sabe dizer se LUIZ GUSTAVO ficava embalando droga no local. Pegava a droga no local e ia vender na esquina de baixo”. Interrogado em juízo, LUIZ GUSTAVO alegou que “estava no local, mas estava fora fumando maconha. É viciado em maconha. Conhecia o policial Graziano, mas não tinha inimizade com ele. Viu os policiais entrando no local e viu a apreensão da droga que estava no local. Não estava na posse da droga. Estava dentro da residência fumando um baseado. CARLOS estudava com seu irmão. Ele o chamou afumar droga no local. Não confessou que estava fracionando a droga. Comprava droga na praça. Sabe que Carlos mexia com droga, mas comprava de outra pessoa. Já tinha a droga que foi fumar na casa de Carlos. No quarto não viu droga e petrechos. Felipe foi buscar droga para entregar para outra pessoa. Ele pegou com CARLOS 110 de maconha e 65 pinos de cocaína. Ele pagou 650,00 nos pinos de cocaína e pagou 2.500,00 na maconha. Viu ele pegando a bolsa e saindo. Não viu ele entregando dinheiro. Seu irmão mexia com droga por isso sabia o preço. O CARLOS não disse o preço na hora para o FELIPE. Levou droga e compartilhou com CARLOS. Não sabe quanto tempo CARLOS mexe com droga. Estava na porta da sala quando a polícia chegou. Não viu a apreensão do material de embalagem e de 186 porções de maconha. No local também estava a vó de CARLOS. Ele correu pelos fundos e é neto da moradora Eva. Foi a primeira vez que encontrou FELIPE no local. Não foi contratado para embalar droga no local”.

NESTES AUTOS (1013630-82.2022.8.26.0451):

- Carlos Alberto Morasco, policial militar, fls. 02; “Estava em patrulhamento ostensivo de rotina pela Rua Professor Mariano da Costa quando, na altura do número 68, visualizou dois indivíduos saindo de uma residência com uma mochila nas costas. Ao avistar a aproximação dos militares, um dos indivíduos, identificado como o indiciado FELIPE, que estava com a mochila, parou repentinamente enquanto o outro, identificado como CARLOS, correu para o interior da casa e foi acompanhado por Graziano. O réu já estava nos fundos da casa. Foi atrás também. De uma porta, saiu de um quarto o LUIZ GUSTAVO. Esse quarto seria de CARLOS, conforme foi informado por Juliane, que apareceu no local também. CARLOS conseguiu fugir pelos fundos. Naquele quarto, tinha droga embalada, faca, maconha esfarelada. Abordaram o LUIZ GUSTAVO. Na mochila de FELIPE foram localizados cinco kits de maconha e sessenta e cinco porções de substância aparentando ser cocaína. FELIPE disse que a droga era de CARLOS e que estavam ali fracionando a pedido de CARLOS e levariam na mochila a droga para entregar a uma pessoa na Praça Jaraguá. Com LUIZ GUSTAVO, nada foi encontrado. No quarto de onde saiu CARLOS, estava foram localizadas cento e poucas porções de substância de maconha, faca, balança de precisão e celular. LUIZ disse que tinha sido convidado por CARLOS para fracionar a droga, mas seria a

primeira vez que estavam fazendo isso. Não sabe há quanto tempo eles agiam em conjunto.

No mesmo sentido, Graziano Ciola Dias, policial militar, fls. 03.

Juliane, irmã de Carlos, disse que não mora no local. Não estava lá. Quem ali residem são a sua avó Eva e seu irmão Carlos. Foi chamada ao local e quando chegou, os policiais ali já estavam. Acompanhou as buscas dos policiais e ele encontraram apenas duas facas. Não tinha droga no momento que estava acompanhando as buscas. Os objetos que os policiais apreenderam estavam no quarto de CARLOS. Das pessoas que foram presas na ocasião, conhece apenas LUIZ GUSTAVO. Ele faz companhia para a sua mãe. CARLOS estava trabalhando naquele dia, fazendo bico de jardinagem quando o "moço" chamava. Quando chegou ao local, os policiais já tinham ingressado na casa. Eva, avó do réu CARLOS, disse que acordou com os policiais já na casa. LUIS estava no local. FELIPE, acredita que não estava. Os policiais encontraram apenas duas facas. Não lembra de nada. Não autorizou os policiais.

Interrogados, os réus negaram os fatos.

CARLOS disse que nem estava no local.

LUIZ GUSTAVO disse que estava na casa com Eva, avó de CARLOS. Ouviu barulho, saiu e viu os policiais no quintal. FELIPE estava do lado de fora da casa. CARLOS estava trabalhando. Os policiais encontraram duas facas e uma caixa de sapato. Nada sabe das drogas.

FELIPE disse que aceitou vender drogas, mas foi apenas naquele dia. Ia ganhar uma diária para vender droga. Não pode falar quem lhe propôs aquele serviço. LUIZ GUSTAVO o chamou para comprar uma "bucha" de maconha com o interrogando. Nesta hora, apareceu a viatura. Os policiais o abordaram, acharam a droga em seu poder e entraram na casa. Conhecia CARLOS de vista. Não sabe se ele estava na casa.

NÃO HÁ DÚVIDAS:

Pouco esclareceu Juliane. Testemunha vinculada subjetivamente ao réu CARLOS, com interesse em favorecê-lo. É sua irmã. Declarações divorciadas das provas dos autos, pois disse que os policiais apreenderam apenas duas facas, quando os documentos dos autos demonstram que muito mais, drogas, balanças e outros objetos, foram encontrados e apreendidos.

E é tão frágil a alegação de que CARLOS estava trabalhando. Os policiais o identificaram sem dúvida como sendo a pessoa que fugiu. E sequer trouxe CARLOS, como testemunha, o "moço" que o teria chamada para trabalhar.

Eva, avó do réu, também nada esclareceu. Declarações divorciadas do contexto dos autos.

A narrativa dos policiais foi firme e uníssona em confirmar que avistaram o momento em que o réu FELIPE com um indivíduo de prenome Carlos saíram da residência.

Outrossim, ao perceberem a aproximação policial, FELIPE parou, enquanto Carlos logrou evadir-se do local. Na mochila trazida por FELIPE foram localizadas 110 porções de maconha e 65 porções de cocaína. Em seguida, os policiais entraram no imóvel onde surpreenderam o réu LUIZ embalando mais entorpecentes. No local, foram apreendidas 186 porções de maconha, além de petrechos usados na embalagem de drogas, como rolos de filme plástico, saquinhos plásticos, duas facas, e uma balança de precisão.

Simples leitura da denúncia já permite a conclusão de que ocorria tráfico de drogas e os policiais agiram em situação de flagrante delito.

A negativa de CARLOS é completamente vazia.

As versões de LUIZ GUSTAVO e FELIPE apresentadas hoje são completamente divergentes das que eles forneceram quando ouvidos em juízo nos autos 1500009-

02.2021.8.26.0599.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: " A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na

medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011). Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10) Considerando as circunstâncias da abordagem, a considerável quantidade e sua forma de embalagem é possível afirmar que a droga se destinava ao comércio ilegal.

Da dosimetria da pena

FELIPE é reincidente, ostentando 2 condenações anteriores (Certidão de fls. 65 - Processo n: 0006936-56.2017.8.26.0451 e Certidão de fls. 64/65 Processo n:0000060-34.2014.8.26.059).

CARLOS ALBERTO é primário.

Mas atuavam de forma associada e manipulavam, traziam consigo e guardavam, considerável quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes. Então, cuida-se de traficantes de certa envergadura, longe da figura do pequeno traficante que a lei penal procura beneficiar.

Portanto, não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

As circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559).

E mais, cabe destacar que o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas instituiu o denominado tráfico privilegiado a prestigiar o princípio da individualização da pena, tendo por objetivo diferenciar as penas impostas ao traficante eventual e àquele que habitualmente se dedica à atividade criminosas.

E nessa seara, após longa discussão doutrinária e jurisprudencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS, reconheceu que a figura do "tráfico privilegiado de drogas", contida no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, não ostenta natureza hedionda, sendo, posteriormente, acompanhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao cancelar o enunciado de sua súmula nº 512.

O privilégio tem o condão de diminuir a pena de um a dois terços e demanda a presença de alguns requisitos cumulativos, quais sejam, a i) primariedade e ii) e bons antecedentes do agente, a iii) não dedicação a atividades criminosas e, por fim, iv) não integração de organização criminosa. Na ausência de um destes elementos inviabiliza-se o reconhecimento da causa de diminuição.

No tocante ao requisito da dedicação a atividades criminosas, tem-se que alguns fatores podem denotar habitualidade e envolvimento no crime, impedindo o reconhecimento da figura privilegiada.

Exemplo disso é a constatação de que o réu tinha grande quantidade e diversidade de drogas.

Ora, as circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559).

É o que permite o art. 42 da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

ANTE O EXPOSTO, pela procedência parcial da ação penal:

Condenando-se FELIPE MANESCO como incurso no artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06 e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO como incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06 combinado com o artigo 29, do Código Penal.

Absolvendo-se LUIZ GUSTAVO DINIZ ESPANA (artigo 386, VII, CPP).

Dada a palavra ao(à)(s) nobre(s) defensor(a)(es) do(a)(s) acusado(a)(s) Carlos e Luiz Gustavo, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiz(a), Carlos Alberto de Oliveira Filho foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n.º 11.343/06 combinado com o artigo 29, do Código Penal.

Luiz Gustavo Diniz Espana foi denunciado como incurso no artigo 35, caput, da Lei

n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 1-4), em data não apurada do mês de dezembro de 2020, ao que consta duas semanas antes do dia 03 de janeiro de 2021, na rua Professor Mariano da Costa, nº 68, bairro Jaraguá, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Felipe Manesco, Luiz Gustavo e Carlos associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta, ainda, que, no dia 03 de janeiro de 2021, por volta de 18h37, na rua Professor Mariano da Costa, nº 68, bairro Jaraguá, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Carlos, agindo em concurso, unidade de desígnios e previamente conluiado com Felipe e Luiz Gustavo, mantinha em depósito, guardava e preparava 186 porções de maconha, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Ainda de acordo com a inicial, os réus estavam associados há aproximadamente duas semanas para a prática de tráfico ilícito de drogas. Para tanto, eles dividiram as tarefas e organizaram-se. Carlos era o responsável pela aquisição do entorpecente e ceder o imóvel, onde os réus reuniam-se para preparação e embalo do entorpecente. Após a preparação da droga, Carlos entregava parte da droga ao Felipe, que era o responsável por vendê-lo. Contudo, na sobredita data, policiais militares patrulhavam pelo referido local, quando avistaram e suspeitaram de dois indivíduos que saíam da residência localizada no endereço mencionado, os quais, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga. Os indivíduos foram identificados como Carlos e Felipe. No local, Felipe foi abordado, enquanto Carlos logrou evasão. Em poder de Felipe, no interior de uma mochila que trazia consigo, foram apreendidas 110 porções de maconha e 65 porções de cocaína. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram à residência de onde eles (Carlos e Felipe) haviam saído e encontraram Luiz Gustavo, momento em que preparava e embalava entorpecentes. No local, foram apreendidas 186 porções de maconha, além de petrechos usados na embalagem de drogas, como rolos de filme plástico, saquinhos plásticos, duas facas, e uma balança de precisão. Diante das circunstâncias apuradas, significativa quantidade de entorpecentes em porções individualizadas e modus operandi, apreensão de material de embalagem, inclusive balança de precisão, apurou-se que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas. Após, apurou-se que Carlos conluiou-se com os comparsas e corréus para a prática delitiva e mantinha e/ou guardava, e preparava o entorpecente, tendo em vista que foi flagrado deixando o local na companhia de Felipe, oportunidade em que logrou evasão, mas veio a ser identificado a posteriori. Outrossim, o modus operandi, significativa quantidade de entorpecente apreendida, material para preparação e embalo e interrogatório do réu Felipe em juízo demonstraram que, em data não apurada, aproximadamente duas semanas antes da prisão em flagrante de Felipe e Luiz, eles associaram-se de forma estável e com divisão de tarefas para a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive já haviam preparado e distribuído vários “kits de droga” no local. O réu Carlos não foi ouvido em solo policial.

Ao serem interrogados, o réu Luiz Gustavo (fls. 13-14) e o réu Felipe (fls. 11-12) exerceram o direito constitucional ao silêncio.

Carlos Alberto Morasco, policial militar, relatou que: “estava em patrulhamento ostensivo de rotina pela Rua Professor Mariano da Costa quando, na altura do número 68, visualizou dois indivíduos saindo de uma residência. Ao avistar a aproximação dos militares, um dos indivíduos, identificado como o indiciado Felipe, parou repentinamente enquanto o outro, identificado como Carlos, correu para o interior da casa e, pulando os telhados das residências vizinhas conseguiu se evadir do local. Na posse de Felipe havia uma bolsa, dentro da qual foram localizadas cento e dez porções de substância aparentando ser maconha e sessenta e cinco porções de substância aparentando ser cocaína. No interior da residência em tela foi localizado um outro indivíduo, identificado como Luiz, sendo que estava embalando drogas. No quarto em que estava foram localizadas cento e oitenta e seis porções de substância aparentando ser maconha e diversos objetos utilizados para preparação de drogas. Ambos os indivíduos confessaram que estavam no local preparando e embalando drogas para posterior venda” (fls. 9).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Graziano Ciola Dias (fls. 10).

Às fls. 472-473, folha de antecedentes do requerido Carlos que indica a primariedade.

Às fls. 80 e fls. 474-475, juntada certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido Luiz Gustavo (fls. 81 – sem atos infracionais).

Às fls. 314-316, laudo de exame dos objetos apreendidos.

Às fls. 374-390, juntado os documentos relacionados ao B.O.P.M. elaborado no dia da prisão de Felipe e Luiz Gustavo.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21-23, fotografias de fls. 24-25, laudo de constatação de fls. 32-35, e laudo de exame definitivo de fls. 310-313.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, ouvido Carlos Alberto Morasco, policial militar. Estava em patrulhamento com o policial Graziano. Viram dois indivíduos saindo de casa, um deles foi contido, era Felipe. O outro entrou na casa, perseguido por Graziano, que acabou não conseguindo pegá-lo. Graziano entrou na casa, Luiz abriu a porta de um quarto que depois soube ser de Carlos, e o depoente avistou drogas sobre uma mesa. O corredor é bem no centro da casa, dentro da casa. Graziano disse que Carlos pegou uma sacola preta e fugiu pelos fundos. Na mochila de Felipe encontraram 5 kits de maconha envolta em plástico filme, e também cocaína em pacotes zip. Felipe disse que a droga era de Carlos e estava no local há algumas horas fracionando entorpecentes. Dentro da casa estava Luiz, e com ele nada encontraram. Chegou Juliane, tia de Carlos, franqueou a entrada, conversou com a mãe dela, que é uma senhora de idade, acompanhou as buscas no quarto de Carlos, ela teria dito que Carlos dava problemas e já tinha sido preso antes. Encontraram drogas no quarto de Carlos. Luz disse que tinha sido convidado por Carlos para trabalhar fracionando drogas, era o primeiro dia. A avó de Carlos falou que eles estavam no quarto há bastante tempo. Felipe e Luiz Gustavo confirmaram que estavam no quarto com Carlos. Não se recorda de denúncias contra os réus. [Sabe se havia estabilidade/habitualidade?] Não sabe. Não colheu informações nesse sentido. Não se recorda de conhecer qualquer dos réus. Perguntado pela Defensoria Pública, informou que Graziano entrou na casa em perseguição a Carlos. Ao perdê-lo, saiu da casa já apresentando Luiz Gustavo. Aguardaram e somente fizeram buscas na casa após a autorização de Juliane, tia de Carlos. Carlos foi reconhecido posteriormente por meio de um documento e também por conta do depoimento da avó e dos demais réus. A tia teria assinado o BO/PM. A avó é muito idosa e debilitada, evitaram aprofundar perguntas com ela em respeito a sua condição. Perguntado pelo advogado de Felipe, relatou que ele contou que naquele dia tinha concordado em participar do fracionamento de droga e da entrega a alguém que ficaria na praça próxima ao local da prisão.

b) Em seguida, ouvido policial militar Graziano Ciola Dias. Relatou que avistaram duas pessoas saindo da casa, abordaram, um foi preso (Felipe), o outro entrou correndo na casa e foi em direção ao fundo, onde há uma segunda casa, e fugiu pelos fundos. Pegou uma sacola ao fugir. Viu Luiz Gustavo saindo de um quarto e também o prendeu. Viu drogas. Luiz Gustavo e Felipe confessaram que estavam picando droga dentro da casa. Chegou uma moça, tia de Carlos. Havia uma senhorinha no local, idosa. Ela estava debilitada. A outra moça acompanhou as buscas. Havia uma mesa de centro no quarto, foram localizadas porções de maconha, facas com resquício de maconha, balança, material para embalo. Também tinha resquício de maconha esfarelada. Os dois rapazes que foram presos disseram que estavam há algumas horas no local ajudando a fracionar entorpecentes. A mochila seria entregue a alguém na rua de baixo, que Felipe não quis identificar. [Como Carlos foi qualificado?] As pessoas que estavam ali falaram que era Carlos e, considerando a qualificação policial anterior, sabe que a pessoa que viu era Carlos. A casa tem uma porta central e, olhando por ela, tem dois cômodos à esquerda e dois à direita. Carlos pegou a sacola e saiu correndo pela porta dos fundos. Viu que uma pessoa abria a

porta do lado esquerdo e a abordou. [Luiz e Felipe disseram algo indicando a pessoa que fugiu como Carlos?] Não se recorda se isso foi colocado no papel, mas durante a ocorrência isso foi falado diversas vezes. Viu a pessoa, depois viu uma foto em documento e os registros criminais de Carlos, tem certeza de que era ele. [Luiz e Felipe disseram algo sobre ser a primeira vez que faziam isso?] Um deles disse que era a primeira vez que participava de fracionamento de drogas, mas não vai saber qual dos dois. [E o outro preso, disse algo?] Sinceramente, não se recorda. Conhecia os réus de abordagens, mas não se recorda quando, mas não percebeu quando avistou as duas pessoas saindo da casa. O que chamou a atenção da polícia foi o comportamento dos dois rapazes quando viram a viatura. Eles travaram. Quando foram fazer a abordagem, Carlos saiu correndo. A memória de que já tinha abordado os réus veio depois. O quarto de onde Luiz saiu era o quarto de Carlos e lá foi encontrada a droga. Soube depois que o quarto era de Carlos, pelas informações prestadas pela família. A moça, Juliane, falou que Carlos dava trabalho há muito tempo mexendo com drogas. Quem abordou Luiz Gustavo não foi o depoente, foi o sub. Morasco. Quem autorizou as buscas na casa foi a senhorinha idosa. Entraram na casa para averiguar uma desobediência. Posteriormente, chamaram a senhorinha e começaram a conversar com ela. O motorista viu droga na bolsa. Luiz Gustavo saiu do quarto falando que tinha droga ali. Estava falando com a senhorinha quando apareceu a outra moça e ela autorizou, apesar da casa não ser dela. A moça era a Juliane. A idosa era lúcida, apesar da idade. Ela passou mal pelo que estava acontecendo. O advogado de Felipe perguntou o que fez o policial se lembrar de outras abordagens de Felipe. Disse que é porque tem boa memória e trabalha há muito tempo em Piracicaba. A ocorrência não envolvia algo ilícito, ou teria efetuado a prisão.

c) Em audiência ocorrida em 09/11/2022, ouvida a testemunha de defesa Juliane Helena Oliveira Gouveia. Sobre os fatos, contou que não estava no local dos fatos, casa da sua mãe, D. Eva. Carlos morava com ela. Mora um pouco para cima. Uma vizinha ligou, disse que a mãe estava passando mal e que a polícia estava na casa. Quando chegou, a polícia já estava dentro da casa. Depois, um policial saiu e a liberou para entrar e acompanhar. A mãe estava sentada do lado de fora da casa, passando mal. Os policiais disseram que iam verificar os cômodos em uma busca. Como era parente, acompanhou. Que se recorda, encontraram na casa duas facas. Não encontraram droga na sua presença. Não se recorda de encontrarem saquinho ou balança de precisão. Sabe que o policial pegou uma caixa de sapato e foi colocando dentro dela. Os objetos recolhidos foram encontrados no quarto do Carlos. Depois disso, os policiais saíram e levaram os dois meninos que estavam fora. Um deles é Luiz Gustavo. Ele faz companhia para D. Eva quando a família precisa. Naquele dia, Carlos estava no trabalho. Na época, ela fazia trabalhos de jardinagem. Sabia que ele não estava em casa porque esse era o combinado: ele estaria fora trabalhando, a tia ia para a igreja e depois iria para a casa da mãe, fazer companhia para ele. Enquanto os familiares não estavam em casa, pediram para Luiz Gustavo ficar com D. Eva, pois ele é pessoa conhecida há muito tempo e ele sempre é chamado com esse fim. Não conhece o outro rapaz, Felipe. Quando chegou, os policiais já estavam dentro da casa, revirando tudo. Não é verdade que autorizou a entrada na casa e as buscas, até porque já estavam mexendo em tudo quando chegou.

d) Em seguida, ouvida a testemunha de defesa Eva Leme da Silva Oliveira. Disse que não foi encontrado entorpecente na sua casa. Estava dormindo, o seu neto estava trabalhando. Quando acordou, sua casa estava cheia de polícia. Não se recorda em que horário os policiais chegaram na sua casa, acha que é à tarde. Carlos trabalha na cooperativa de reciclagem. Nesse dia, ele tinha saído para trabalhar e não tinha retornado ainda. Estava em casa acompanhada por Gustavo. Ele fica lhe acompanhando quando o neto Carlos se ausenta. Felipe não estava na sua casa, não sabe quem é. Acordou, escutou barulho, foi ver o que estava acontecendo, os policiais encostaram os meninos na parede e foram entrando. Começou a passar mal, um dos policiais a colocou sentada no portão. Os vizinhos chamaram a filha Ju. Os policiais saíram com uma caixa de sapato com duas facas velhas, que era de outro filho. Os policiais levaram Gustavo e um outro, que não sabe quem é. Não autorizou os policiais a entrarem na sua casa. Sequer comunicaram a ela que iam entrar. Quando viu, já estavam dentro da casa. Carlos sai de casa 4h30 da manhã para trabalhar. Volta às

18h. Se o neto tem envolvimento com drogas, era muito escondido, não tem conhecimento.

d) Interrogado o réu Luiz Gustavo Diniz Espana. Estava na casa cuidando da avó de Carlos. Dona Eva estava deitada. Ouviu um barulho, saiu no corredor para ver o que estava acontecendo. Os policiais já estavam nesse corredor. Disseram “perdeu” e lhe prenderam. Colocaram-no para fora e chegou reforço. O Felipe estava fora da casa. Carlos estava trabalhando. Os policiais encontraram dentro da casa duas facas e uma caixa de sapato. Não reconhece a droga que foi apreendida. Não sabe onde estava a droga apreendida. Já estava fora da casa quando os policiais fizeram a revista. Não compra droga de Carlos. Não viu se Felipe tinha drogas com ele, pois estava dentro da casa. Nunca viu Felipe comprar drogas de Carlos, nem ficou sabendo dessa informação. Quando os policiais chegaram, Carlos não saiu pelos fundos da casa. Perguntado sobre a sua versão em outro processo, no qual foi julgado por tráfico em relação aos mesmos fatos, disse que não acusou ninguém. Conhece os policiais de vista.

c) Por fim, ouvido o réu Carlos Alberto de Oliveira Filho. No dia dos fatos, saiu de casa para trabalhar e, quando retornou, ficou sabendo que prenderam os meninos na frente da sua casa e que a polícia entrou no seu imóvel. Na época, trabalhava com jardinagem. Sua tia e sua avó lhe contaram que os policiais saíram com uma caixa de sapato, com duas facas dentro. Ficou sabendo também que Luiz Gustavo foi preso. Estava trabalhando em companhia com uma pessoa chamada Miranda. Tinham ido fazer jardinagem em um condomínio, acha que o nome é Damha. Desconhece a existência de drogas em seu quarto. Não tinha vendido nenhum entorpecente para Felipe. Não permitia que Luiz Gustavo entrasse na sua casa com droga. De vez em quando, fumam um baseado, mas não permite que ninguém entre na sua casa com drogas. Luiz Gustavo estava ali para ficar com a avó. Não estava agindo com Felipe e Luiz Gustavo para prática de tráfico. É usuário de maconha. Não tem nada contra os policiais.

c) Iniciados os interrogatórios, o réu Felipe Manesco disse que aceitou vender droga no dia dos fatos. Estava desempregado. Ia vender só naquele dia, ia receber uma diária. Não pode falar quem lhe entregou as drogas, pois pode se prejudicar. Pegou a droga naquele dia. Passaram na rua dos fatos e lhe deixaram as drogas. Luiz Gustavo lhe chamou para comprar uma bucha de maconha com ele. Foi nessa hora que a polícia apareceu. Luiz estava no portão da casa e Felipe estava na calçada. Quando foi sair, a polícia lhe abordou. Eles lhe abordaram, acharam a droga com ele e entraram na casa. Colocaram Luiz Gustavo para fora e ficou um policial dentro da casa. Passou uns 20 minutos, a filha da senhora chegou. Antes, o policial já tinha mostrado para eles uma sacolinha cheia de drogas, não sabe quais eram, se era a que estava com ele. Conhecia Carlos mais de vista, pois moram de frente. Não sabe dizer se Carlos estava na casa. Quem viu sair da casa foi Luiz Gustavo, que foi comprar uma bucha de maconha. Depois, foram levados para a delegacia. Não estava unido a Luiz Gustavo e Carlos para vender drogas. Nunca teve envolvimento com nada, pegou para vender somente naquele dia. Não tinha nenhum envolvimento com Carlos ou Luiz Gustavo. Usava maconha na época, fumava quase todo dia, mas conseguia ficar sem fumar. Perguntado se Luiz Gustavo é a pessoa que saiu correndo, explicou que ninguém saiu correndo. A polícia entrou na casa porque Luiz Gustavo estava fechando o portão.

- DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO

Preliminarmente, deve-se reconhecer a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do acusado Luiz Gustavo, eis que a entrada no local se deu com violação ao princípio constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio. Isso porque não há prova nos autos de que houve consentimento de pessoa que ali residia para ingresso no local.

De início, restou claro que a entrada na casa não foi autorizada por qualquer dos moradores. As testemunhas Juliane e Eva foram claras: não autorizaram a entrada e, quando viram, a polícia já estava dentro do imóvel.

E não se diga que a entrada no imóvel é justificada pelo achado das drogas na mochila de Felipe, na frente da casa.

Conforme consta do depoimento dos policiais militares nos autos do processo n. 1500009-02.2021.8.26.0599, nos quais os réus Felipe e Luiz Gustavo respondem por

tráfico de drogas em relação aos mesmos fatos aqui discutidos, os policiais responsáveis pela apuração dos fatos estavam em patrulhamento pelo local quando “avistaram e suspeitaram da conduta do Felipe e de terceiro não identificado”. Apesar de não existir urgência na situação, e apenas tendo como “prova” essa suspeita genérica, temerariamente procederam à abordagem de Felipe (o terceiro evadiu-se). Enquanto um dos policiais revistava Felipe, o outro já entrou na casa, sem ainda ter a informação de que com ele, em uma mochila, tinham sido localizados entorpecentes.

Em seu depoimento, o Sd. Graziano Ciola foi claro, indicando que entrou na casa enquanto o seu companheiro de farda, policial Morasco, revistava Felipe, vindo a saber posteriormente que foram localizadas drogas com ele.

O policial Graziano Ciola, sem ter providenciado um mandado de busca e apreensão e sem obter autorização para o ingresso no local, ingressou na residência –, momento em que localizou o recorrente Luiz Gustavo e diz ter apreendido as demais substâncias entorpecentes.

Ainda que os policiais tenham entrado no terreno da residência em perseguição à pessoa de nome “Carlos”, que, conforme relataram, viram pular o muro e fugir pelos fundos, a continuação da diligência naquele imóvel não tinha justificativa.

Como se observa, não havia nenhum indício ou justa causa para que o cômodo (quarto) em que Luiz Gustavo estava fosse vistoriado. Aliás, o policial que entrou na casa, Graziano, sequer sabia o que havia na mochila de Felipe – que ficou do lado de fora, detido pelo policial Morasco –, pois saiu no encalço de uma pessoa que fugiu da abordagem policial (supostamente Carlos), sem ainda saber o motivo da fuga. Mesmo depois de ver essa pessoa pular o muro, Graziano entrou na casa e, mais especificamente, no quarto onde estava Luiz Gustavo, não podendo dizer que o fazia porque havia suspeita de tráfico – como já dito, a descoberta das drogas na mochila de Felipe se deu enquanto o policial Graziano já estava vistoriando a casa.

Considerando a dinâmica do ocorrido, verifica-se que a vistoria nos cômodos da casase deu em desconformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. O suspeito perseguido já tinha se evadido, pulando o muro dos fundos, e o policial que adentrou o terreno da residência em perseguição sequer sabia o que ocorria na calçada, onde Felipe era detido e sua mochila era vistoriada. Não havia fundadas razões. O achado posterior da droga com Felipe não legitima a busca domiciliar ilícita realizada pelo policial Graziano, que agiu sem ter conhecimento do que buscava, e com a certeza de que o fugitivo que perseguiu tinha saído daquela residência.

Se é assim, deve ser frisado que, não obstante seja permitida a busca pessoal independentemente de mandado judicial (CPP, artigo 244), a busca domiciliar somente poderá ser realizada quando o ingresso na residência for legítimo, isto é, com “[...] o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (CF, artigo 5º, inciso XI).

Importante ressaltar que embora o artigo 241 do CPP pareça autorizar a busca domiciliar sem a prévia expedição de mandado de busca, ele não foi recepcionado pela atual Constituição Federal, art. 5º, XI. De acordo com Gustavo Badaró:

O dispositivo é criticável. A CR [Constituição Federal] estabeleceu que a garantia da inviolabilidade do domicílio somente pode sofrer restrição mediante ordem judicial (art. 5º, XI). Assim, salvo hipótese de flagrante delito, mesmo que a busca seja realizada pela autoridade policial, será necessária a determinação judicial e, conseqüentemente, a expedição do mandado de busca (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 516).

Na mesma linha, Antonio Magalhães Gomes Filho esclarece que:

Exige-se para a busca domiciliar, como visto, a expedição de um mandado judicial, uma vez que a Constituição garante a inviolabilidade da casa do indivíduo, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia